

1500342-82.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... do Estado de São Paulo)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRITÉRIO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. REGIME FECHADO. NECESSIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Embora não hediondo o crime de tráfico privilegiado, a quantidade e qualidade da droga obstam a fixação do regime mais brando. 3. Negado provimento ao recurso. (APR

10702100791806001 MG Orgão Julgador: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500342-82.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2080813/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 23818543 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2080813 - DEL.POL.VARGEM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

JULIO CESAR MARTINS foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e

artigo 33, § 1º, inciso I, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, porque no dia 23 de março de 2022, na Rodovia BR 381, Km 07, cidade de Vargem, nesta Comarca, visando alcançar o Estado de Minas Gerais, transportava, para consumo de terceiros, sete pacotes de pó branco contendo cocaína, cafeína, lidocaína e tetracaína, pesando aproximadamente 7.130 quilos, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, bem como insumos adulterantes na preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 191/196. Por decisão datada de 08 de junho de 2022 (fl. 207), rejeitou-se a denúncia com relação ao delito capitulado no artigo 33, caput, da lei especial. Na mesma data, procedeu-se ao recebimento da denúncia e de seu aditamento quanto ao crime previsto no artigo 33, § 1º, inciso I, cc. artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fls. 281).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia e de seu aditamento, certa de que as provas dos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 313/333 e 353).

A defesa pugnou pela absolvição embasada na atipicidade dos fatos, a par da ausência de dolo e na fragilidade das provas colhidas, postulando, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tipo penal em sua forma privilegiada (fls. 338/353).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, para fins do inciso I, do § 1º, do artigo 33, da lei de drogas, deve-se pontuar que a expressão "matéria-prima" abrange não só as substâncias destinadas exclusivamente à preparação de drogas, mas também aquelas que, eventualmente, se prestam a esse objetivo, tais quais a cafeína e a lidocaína.

Acerca da tipicidade da infração, qual seja, ter em depósito material químico ou insumo destinado à preparação de drogas, o e. STJ já teve, especificamente acerca da cafeína e lidocaína, oportunidade de reconhecer a ocorrência como violadora do art. 33, § 1º da lei de regência, confira-se:

""PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 33, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 11.343/06. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA-PRIMA DESTINADA A PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTE. LIDOCAÍNA E CAFEÍNA. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que não há falar-se em 'atipicidade da conduta se o paciente foi preso, em flagrante, ao trazer consigo lidocaína e cafeína, matérias-primas comumente destinadas ao aumento de quantidade e volume de substância entorpecente' (HC 45003/SP, Rel. Ministro OG Fernandes, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 26/10/2009). Súmula 568/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ - AgInt no Resp nº 1.655.319/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04.05.2017, DJe 11.05.2017. Em conclusão idêntica: HC nº 488.375/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 21/03/2019, DJe 02/04/2019).

Assim, uma vez superada a questão da tipicidade, porque os materiais apreendidos neste caso importariam insumo, ou seja, elementos necessários para comumente produzir cocaína, verifica-se que a materialidade do delito previsto no artigo 33, § 1º, inciso I, da lei especial, está plenamente comprovada.

Os laudos de exame químico toxicológico (fls. 118/120 e 122/124) descreveram e concluíram que as substâncias analisadas são cafeína, lidocaína e tetracaína, caracterizadas por meio de análises químicas e cromatográficas.

Tais substâncias, conquanto não sejam consideradas entorpecentes pela legislação em vigor, eis que não se encontram relacionadas no Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344 e suas atualizações, podem ser, e normalmente são, em razão de suas características físicas (pó branco) e propriedades farmacológicas (anestésico local/estimulante),

utilizadas como diluente de cocaína, com o intuito de aumentar o volume do entorpecente e com isso elevar os lucros auferidos neste comércio ilícito. Lado outro, tais substâncias encontram-se presentes na Lista II do Anexo I da Portaria nº 1.274, de 23/08/03, estando seus empregos sujeitos ao controle e fiscalização pela Polícia Federal nas quantidades previstas pelo adendo da supracitada lista, em conformidade com a Lei nº 10.357, de 27/12/01, que estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica '. De fato, a Cafeína e a Lidocaína estão arroladas na Lista II, do Anexo I, da Portaria nº 1.274, de 25 de agosto de 2003, expedida em observância ao Decreto nº 4.262, de 10 de junho de 2002, responsável pela regulamentação da Lei nº 10.357, de 27 de dezembro de 2001, a qual, consoante já referido anteriormente, 'estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica, e dá outras providências.

Assim, em que pese aludidas substâncias não serem consideradas entorpecentes, sua compra, venda, comercialização, aquisição, posse, transporte e importação estão sujeitas a controle, somente podendo ser efetivadas nos termos das determinações legal e regulamentar que regem a matéria.

A autoria, igualmente é certa, não obstante as escusas inconvincentes do acusado, que em seu interrogatório negou a prática da infração.

Em juízo, muito embora Júlio Cesar tenha admitido que transportava o material, defendeu-se dizendo que desconhecia que se tratava de produto utilizado na preparação de drogas.

Disse que é motorista particular e que naquela ocasião foi contratado por uma pessoa chamada Tadeu, para que transportasse um produto químico de São Paulo até a cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Aduziu que "Tadeu" fez contato por meio de um grupo de motoristas de UBER que ambos participavam, quando então lhe perguntou se ele se poderia ir até São Paulo e buscar um produto químico utilizado em ração para gado.

Narrou que combinou o valor e se dirigiu a São Paulo, numa rua em Capão Redondo, indicada pela pessoa que o contratou. Chegando ao local, apareceu uma pessoa de moto e lhe entregou a sacola de papelão, contendo o material. Na sequência, seguiu para Pouso Alegre, onde deveria entregar a mercadoria num endereço que seria posteriormente informado. Contudo, quando seguia pelas proximidades do pedágio, foi abordado por policiais rodoviários que, após fiscalização, apreenderam o material e lhe informaram que a princípio, tratava-se de cocaína. Finalizou dizendo que em momento algum sabia da ilicitude do material transportado, acreditando que se tratava de um produto químico destinado a preparo de ração para gado.

Sua escusa não convenceu e restou isolada.

Primeiro porque Júlio Cesar sequer identificou a pessoa que supostamente teria lhe contratado para o transporte do material. Não bastasse, muito embora tenha argumentado que referida pessoa teria lhe contratado por meio de um grupo de Uber, nenhuma prova fez nesse sentido.

Ora, se de fato houvesse mensagens entre eles no seu aparelho celular, assim como o endereço que teria sido indicado como sendo o local para retirada do produto, informação esta que segundo o acusado também estaria em seu aparelho celular, certamente teria postulado a apresentação dos "prints" das mensagens existentes, o que facilmente seria obtido com o desbloqueio do aparelho celular apreendido. Acrescente-se, ainda, que ele também não comprovou que realizava viagens na qualidade de motorista de UBER.

De igual forma, deveria suspeitar que ao realizar o transporte de mercadoria sem nota e sem lugar de destino declarado, certamente estaria incorrendo em algum ilícito.

Repise-se, nenhuma prova fez nesse sentido, ônus que lhe incumbia.

Ao depois, durante a etapa policial ele se calou:

"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não

inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em Juízo".

Percebe-se que se Júlio Cesar desconhecesse a ilicitude do material apreendido na ocasião de sua prisão, certamente teria declarado tal situação durante seu interrogatório extrajudicial. Somente em Juízo ele apresentou tal versão. Destarte, tendo o acusado inobservado as disposições legais e regulamentares incidentes na espécie, bem assim constituindo a Cafeína e a Lidocaína substâncias utilizadas como 'matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas ', vez que empregadas na preparação da cocaína, resta a conduta a ele imputada subsumida à previsão do artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06. Portanto, a par da força de convencimento ínsita nos argumentos expostos, corroboram a certeza da autoria os depoimentos seguros e harmônicos das testemunhas ouvidas durante a instrução.

Senão vejamos.

O Policial Rodoviário Fábio relatou que naquela ocasião realizava patrulhamento de rotina pela Rodovia Fernão Dias quando abordou o condutor do veículo Logan, de cor branca. Realizada revista veicular, localizou no porta-malas sete pacotes contendo uma substância branca. Indagado sobre aquele material, o acusado lhe informou que teria recebido o produto de um desconhecido no Capão Redondo, em São Paulo, e que o levaria para Pouso Alegre. Por fim, informou que depois de realizar o narco-teste daquele material verificou o resultado positivo para cocaína, motivo pelo qual o conduziu à Delegacia de Polícia.

Suas palavras são confirmadas pelo policial Eduardo, que de forma séria e coerente descreveu a apreensão do material no interior do veículo conduzido pelo acusado. Nada existe nos autos a demonstrar que os policiais responsáveis pela prisão do acusado tivessem qualquer motivo para imputar a ele, indevidamente, a prática de crime, em especial da gravidade do denunciado. Por seus conteúdos, eles são suficientes a comprovar a situação de traficância.

Por isso mesmo, a intenção de comerciar fica consubstanciada visto que tais provas apontam claramente para esta finalidade do agente. Não há nada que possa desabonar o depoimento dos policiais envolvidos, pois seus atos presumem-se legítimos por força de princípio administrativo.

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito".

Assim, o argumento de que seus depoimentos estariam comprometidos pelo fato de terem o dever legal de justificar sua atividade não pode ser aceito. Se o fosse, estaria estabelecido preconceito odioso em relação a pessoas que auxiliam a justiça na busca da verdade real.

Destarte, seus depoimentos são analisados e cotejados com os demais elementos carreados aos autos, sem maior ou menor relevância pelo fato de serem agentes de segurança do Estado, responsáveis pela repressão ao crime.

Neste diapasão, tem se manifestado a jurisprudência ao tratar do depoimento policial.

Veja-se:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

Acrescente-se, ainda, que o acusado conduzia um veículo locado, de propriedade de Denizete. Na documentação apresentada pela proprietária do carro visando a sua liberação, verifica-se a existência de um áudio enviado pelo acusado ao locador do veículo, informando a impossibilidade de devolução do bem no dia 23/03/2022. Conforme se observa à fl. 147, o acusado enviou um áudio para Ricardo, responsável pela locação, por volta de 16h54', ocasião em que informou que teria levado um passageiro em Jacutinga e que em razão disso, não teria tempo para devolver o veículo naquele mesmo dia, no horário das 18horas.

Vejamos o teor do documento:

"14) AUDIO DO DIA 23/03/2022 (Quarta-feira) (HORÁRIO: 16:54): "Fala Ricardão, Boa tarde, o Ricardo, vim trazer um passageiro em Jacutinga mano, acho que não vai dar tempo de voltar até seis beleza? Amanhã cedo no primeiro horário eu vo lá levar procê lá umas ove horas poder ser?"

Pontue-se que o acusado foi abordado por policiais no dia 23/03/2022, por volta das 19h30", na Rodovia Fernão Dias, quando retornava da cidade de São Paulo. Portanto, evidente que ele mentiu ao locador do veículo quando informou que estava na cidade de Jacutinga, quando na verdade se encontrava no Estado de São Paulo. Tal fato contribui para demonstrar que o acusado sabia perfeitamente a ilicitude do material que transportava.

Destarte, a quantidade do material apreendido, o local e as circunstâncias como foi surpreendido, tudo indica para uma guarda com a intenção de utilização no tráfico de drogas.

Assim, a identificação de substância diversa daquela inicialmente descrita (cocaína), não tem o condão, no caso concreto, de afastar a tipicidade da conduta, mas apenas lhe empresta tipificação distinta, com o deslocamento da figura prevista no caput do art. 33 da L e i 11.343/06, para aquela contemplada no parágrafo 1º do mesmo dispositivo, na esteira do aditamento realizado pela acusação, razão pela qual a procedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 33, § 1º, I, DA LEI Nº 11.343/2006. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA-PRIMA DESTINADA A PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTE. LIDOCAÍNA E CAFEÍNA. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que não há falar-se em atipicidade da conduta se o paciente foi preso, em flagrante, ao trazer consigo lidocaína e cafeína, matérias-primas comumente destinadas ao aumento de quantidade e volume de substância entorpecente "(HC 45.003/ SP, Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 26/10/2009).

"RECURSO ESPECIAL Nº 1.655.319 -SP (2017/0036280-7) RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZADE ASSIS MOURA RECORRENTE: ANGEL ROLANDO GONZALEZ ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 33, § 1º, I, DA LEI Nº 11.343/2006. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA-PRIMA DESTINADA A PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTE. LIDOCAÍNA E CAFEÍNA. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. DECISÃO. Trata-se de recurso especial interposto por ANGEL ROLANDO GONZALEZ, com fundamento na alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 480/481): "PENAL: TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS -MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO -DOSIMETRIA DA PENA I - Embora não tenham sido objeto de recurso, materialidade e autoria estão comprovadas. A materialidade do delito do artigo 33, § 1º, I, da Lei 11.343/2006 está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03/09), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 13/15), pelo Laudo Preliminar de Constatação (fls. 26/28) e através do Laudo de Química Forense (fls. 76/79), os quais comprovaram que o material encontrado em poder da réu trata-se de cafeína e lidocaína, substâncias químicas destinadas à preparação de cocaína. A autoria, por sua vez, foi demonstrada pela prisão em flagrante do acusado e pelo depoimento das testemunhas. II - As substâncias químicas cafeína e lidocaína, encontradas em posse do acusado, embora

não relacionadas na lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, encontram-se relacionadas na lista II dos produtos químicos sujeitos a controle de fiscalização pelo Departamento de Polícia Federal, de forma que não aproveita a alegação da defesa de ausência de tipicidade material. III - Conforme demonstrado pelo laudo apresentado, o acusado transportava o equivalente a 2.048g (dois mil e quarenta e oito gramas) de cafeína e lidocaína, substâncias químicas destinadas à preparação de cocaína. No entanto, não obstante se reconheça o potencial ofensivo da cocaína, a quantidade de insumos apreendida não justifica a fração aplicada pelo Juízo na fixação da pena-base, que fica reduzida para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias- multa. IV - Considerando que o réu confessou a prática do delito, é de lhe ser reconhecida nesta sede a atenuante da confissão espontânea. Não obstante, a pena é de ser mantida em seu mínimo legal, tendo em conta a Súmula 231 do STJ. Em seu recurso especial, às fls. 512/518, o recorrente assenta negativa de vigência ao artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que é de rigor a absolvição quanto à prática do crime previsto no dispositivo em referência, ante a atipicidade da conduta, pois as substâncias lidocaína e cafeína apreendidas não constituem matérias-primas destinadas à preparação da cocaína. Destacou que "a lidocaína e a cafeína não se encontram na RDC nº 19, de 24.03.2008, da ANVISA, Portaria nº 344, da SVS/MS, de 12.05.1998" (fl. 515), e desse modo, a posse dessas substâncias não pode configurar tráfico de drogas. Ressaltou que a importação ou guarda da lidocaína, pode configurar, quando muito, mero ato preparatório, o que não é punível pelo direito penal. No que tange à negativa de vigência ao artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que é de rigor a absolvição quanto à prática do crime previsto no dispositivo em referência, ante a atipicidade da conduta, pois as substâncias lidocaína e cafeína apreendidas não constituem matérias-primas destinadas à preparação da cocaína, constata-se que o raciocínio jurídico adotado pela Corte de origem guarda fina sintonia com a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, sobre a matéria. De fato, quanto ao tema, assim consignou a Corte a quo (fls. 472/473): "Atipicidade da conduta Para a configuração do delito do artigo 33, § 1º, I, da Lei 11.343/06 é suficiente a importação, em desconformidade com as disposições legais ou regulamentares, de substância que possa ser usada para a produção de entorpecentes, sendo desnecessária, para atender aos elementos objetivos do tipo penal, a efetiva produção de entorpecentes. Com efeito, o objeto material do delito é a 'matéria prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas', tratando-se de norma penal em branco, complementada pela Lei 10.357/01, pelo Decreto 4.262/02 e pela Portaria MJ 1.274/03, que especifica os produtos químicos sujeitos a controle e fiscalização. No caso dos autos, as substâncias químicas cafeína e lidocaína, encontradas em posse do acusado, embora não relacionadas na lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, encontram-se relacionadas na lista II dos produtos químicos sujeitos a controle de fiscalização pelo Departamento de Polícia Federal. Logo, não aproveita a alegação da defesa de ausência de tipicidade material. Assim, em vista da prisão em flagrante do acusado, dos depoimentos colhidos e dos laudos apresentados, demonstrando que ele, de forma livre, voluntária e consciente, praticou o delito descrito na denúncia (33, § 1º, I, c/c artigo 40, I, da Lei 11.343/2006), sua conduta se amolda ao tipo penal referido, devendo ser mantido o decreto condenatório". Dessarte, percebe-se que a linha de inteligência jurídica desenvolvida pelo Tribunal a quo possui ressonância na jurisprudência deste Sodalício Superior. Com efeito, esta Corte Superior de Justiça tem entendido que não há falar-se em "atipicidade da conduta se o paciente foi preso, em flagrante, ao trazer consigo lidocaína e cafeína, matérias-primas comumente destinadas ao aumento de quantidade e volume de substância entorpecente" (HC 45.003/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 26/10/2009).

E ainda:

Apelação - Tráfico (artigo 33, §1º, inciso I, e §4º, c.c. art. 40, incisos III e V, todos da Lei nº 11.343/06) - Pretensão à aplicação do redutor máximo previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas - Não acolhimento - Acusada que admitiu a traficância, tendo sido surpreendida em poder de expressiva quantidade de

substância ilícita - Pretensão à imposição de regime inicial menos rigoroso - Impossibilidade - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Inviabilidade de aplicação da detração penal (artigo 387, §2º, CPP) - Questão afeta ao Juízo da Execução Criminal - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500334-17.2021.8.26.0618; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pindamonhangaba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/03/2022; Data de Registro: 18/03/2022).

Apelação. Crime de tráfico de insumos para a preparação de drogas. Preliminares de nulidade do processo - irregularidade na abordagem, e falta de materialidade. Rejeição. Absolvição, ou por erro de tipo, ou por erro de proibição. Não cabimento. Autoria, materialidade e indicação de traficância demonstradas. Desclassificação para o crime previsto no artigo 34 da Lei nº 11.343/06. Não cabimento. Atenuação das penas. Não cabimento. Não provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Criminal 1523631-93.2020.8.26.0228; Relator (a): Zorzi Rocha; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/04/2022; Data de Registro: 08/04/2022).

TRÁFICO DE ENTORPECENTES (artigo 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06) e PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (artigo 14 da Lei nº 10.826/03) - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares e peritos em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada - Apreensão de expressiva quantidade de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, conforme Portaria MJSP nº 240/2019 e laudo complementar prevalente de fls. 188/189 (um tijolo contendo lidocaína e cafeína, com massa líquida de 1,034 quilogramas) - Condenação mantida. PENAS E REGIME PRISIONAL - Bases acima dos mínimos. Mau antecedente e quantidade de substâncias destinadas à preparação de drogas. Tráfico (1/5). Porte de munições de uso permitido (1/6). Proporcionalidade - Reincidência e agravante do artigo 61, II, j, do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública). Exasperação adequada (1/5) - Bis in idem não configurado. Diferentes condenações transitadas em julgado que foram utilizadas em fases distintas da dosimetria - Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas - Regime inicial fechado - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) - Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500933-05.2021.8.26.0537; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/11/2021; Data de Registro: 08/12/2021)

Destarte, bem comprovadas a autoria e materialidade da infração, ficando sem guarida as combativas alegações da defesa.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Ele não ostenta antecedentes criminais e os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, estes fatos de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. Não há participação de vítima no tráfico a ser considerada na dosimetria da pena.

No entanto, levando em consideração as circunstâncias do crime, a par da quantidade do material apreendido, em obediência ao teor do artigo 42, da Lei 11.343/2006, vemos que as penas-base comportam acréscimo por conta deste fator.

Presente a circunstância judicial acima exposta, que deve levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa no patamar mínimo legal.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar.

Na etapa final a causa especial de aumento denunciada deve incidir.

É certo que o condenado transportava o material entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais, caracterizando o tráfico entre tais unidades da federação. Assim

indicam os depoimentos existentes nos autos, que comprovam que ele estava seguindo rumo ao Estado de Minas Gerais. Logo, as penas serão acrescidas de 1/6 (6 anos + 1/6 = 07 anos/ 600 + 1/6 = 700 dias).

O acusado é primário, portador de bons antecedentes criminais e, nestes autos, não se demonstrou que ele tenha envolvimento ou integre organização criminosa. Logo, amolda-se na hipótese da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Assim sendo, suas penas serão diminuídas em 1/6, pois não existem motivos a justificar maior redução em virtude da quantidade do insumo (7 anos - 1/6 = 5 anos e 10 meses /700 - 1/6 = 583 dias).

Não obstante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao reconhecimento da desconsideração da hediondez ao tráfico privilegiado, o que possibilitaria o cumprimento inicial de pena em regime mais brando, in casu, ante a quantidade do material apreendido em poder do condenado, aproximadamente 8 quilos de cafeína/lidocaína, o regime inicial será o fechado, visto que, qualquer outro regime não contribuiria para a reprovação do crime e ressocialização do agente.

Nessa esteira:

EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA - DISCUSSÃO ENVOLVENDO O REGIME PRISIONAL CABÍVEL E A APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS - BENEFÍCIOS INAPLICÁVEIS NA ESPÉCIE - RÉU QUE TRAFICAVA, ALÉM DE MACONHA, TAMBÉM COCAÍNA, DROGA ESTA DE EFEITOS NEFASTOS À SAÚDE DE USUÁRIOS E VICIADOS - NECESSIDADE DE ENÉRGICA REPROVAÇÃO - ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA, QUE JUSTIFICA A RECUSA DOS BENEFÍCIOS, A DESPEITO DA NÃO-HEDIONDEZ DO CRIME - RECURSO DESPROVIDO. (EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 0100260-13.2015.8.26.0050/50000 Comarca: SÃO PAULO - Processo nº 0100260-13.2015.8.26.0050 Juízo de Origem: 8ª Vara Criminal Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal Embargante: LUCAS SANTANA BATISTA Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRITÉRIO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. REGIME FECHADO. NECESSIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Embora não hediondo o crime de tráfico privilegiado, a quantidade e qualidade da droga obstam a fixação do regime mais brando. 3. Negado provimento ao recurso. (APR 10702100791806001 MG Órgão Julgador: Câmaras Criminais Isoladas / 7ª CÂMARA CRIMINAL. Publicação: 11/01/2013. Julgamento: 13 de Dezembro de 2012. Relator: Marcílio Eustáquio Santos).

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese. Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014).

O condenado não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta

Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR JULIO CESAR MARTINS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, § 1º, inciso I, e § 4º, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica. Recomende-se na prisão onde ele estiver.

Com o trânsito em julgado, promova as comunicações de praxe e adote o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 20 de setembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA